

1522113-34.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522113-34.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522113-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO ANGELO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JULIANO ÂNGELO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 1º e §4º, incisos I e II, combinado com art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, "j", todos do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 04h20min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Avenida Antonelo da Messina, nº 1915, Sítio do Piqueri, São Paulo/SP, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em 1 caixa contendo doze baralhos, 4 caixas de chocolate e a quantia de R\$ 1.400,65 (mil, quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos), pertencentes à empresa vítima Lojão do Real, representada por M.R.S., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida, o réu foi citado notificado e apresentou resposta à acusação em audiência.

Em cumprimento ao disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do acusado foi substituída por medidas cautelares, consoante decisão de fls. 114/115.

Após a manutenção do recebimento da denúncia e não sendo o caso de acordo de não persecução penal, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima e um policial.

As partes desistiram da oitiva da testemunha faltante, o que foi devidamente homologado.

O réu não encontrado, no endereço por ele fornecido, quando de sua soltura, e assim sendo foi declarado revel, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal e assim não foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155, Código Penal.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, invocando a figura do crime impossível, sob o argumento de que o representante legal da empresa possuía dispositivo de vigilância conectado em seu aparelho celular o que por certo impediria a consumação do crime. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da qualificadora referente à escalada; o reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com agravante da reincidência; além da fixação do regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há que se falar em crime impossível como requerido pela Defesa, já que bastaria que o réu conseguisse fugir na posse das mercadorias subtraídas e não fosse inteceptado pela polícia, para que o crime tivesse se consumado e portanto, não estão presentes os requisitos previstos no art. 17, do Código Penal.

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento da jurisprudência, como a seguir se demonstra:

"[...] A vigilância por meio de circuito interno de vídeo ou realizada por seguranças em estabelecimentos comerciais não torna impossível a consumação do furto. Embora tais elementos dificultem a empreitada criminosa, inegável a existência de margem para que o agente ludibrie a segurança e conclua o seu intento. [...]" (AgRg no REsp 1221022 SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013)

E não é outro o teor da súmula Súmula 567 do STJ - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

E mais: "[...] 'Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o monitoramento por meio de câmeras de vigilância, de sistemas de alarme ou a existência de seguranças no estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação da infração.' (AgRg no REsp 1133055/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 251/01/2011). [...]" (AgRg no AREsp 258.347 MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

"[...] A existência de sistema de vigilância, ou mesmo de vigias, em estabelecimentos comerciais não torna impossível a prática de furto, embora reduza consideravelmente a probabilidade de êxito na empreitada criminosa. [...]" (AgRg no REsp 1206641 RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 21/03/2012).

Afastada a tese de impossibilidade do crime, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitiva veio devidamente comprovada pelo relatório investigativo e laudo pericial de fls. 136/140, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

A vítima M. R. da S. proprietário do estabelecimento comercial, "Lojão do Real", ao ser ouvida em juízo, disse que estava em sua residência e ao visualizar pelas câmeras de seu celular o aplicativo de segurança da loja, percebeu que um indivíduo invadindo seu estabelecimento e subtraindo produtos do interior da loja e, em razão disso, discou imediatamente para o 190 para informar o ocorrido. Após solicitar o auxílio da polícia se dirigiu ao estabelecimento comercial e constatou que havia um vidro quebrado, duas portas arrombadas e a fiação das câmeras também estava

danificada e logo em seguida foi comunicado pelos policiais, que ali já estavam, que o réu fora encontrado dentro de seu estabelecimento comercial já de posse de vários objetos que seria por ele subtraídos. Disse, ainda que foi constatado que o réu entrou no local pelo telhado.

Por outro lado o policial Gilmarcio de Souza Bispo, ao ser ouvido em juízo, disse que foi acionado pela vítima para atender uma ocorrência de furto em andamento em um estabelecimento comercial e ao chegar no local deparou-se com o réu que foi abordado ainda com os objetos da vítima em suas mãos. Alegou, ainda que o portão do imóvel estava arrombado e que o estabelecimento foi devidamente periciado.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

A qualificadora da escalada, contudo, não veio devidamente comprovada nos autos, nenhuma das pessoas ouvidas visualizou o réu entrando na loja. Ademais, não obstante as alegações do Ministério Público, não há nos autos provas concretas de que o crime foi praticado mediante escalada, já que os vestígios encontrados no imóvel após perícia não apontam que o réu ingressou no imóvel pelo telhado, ao contrário o laudo pericial é conclusivo no sentido de que: "Diante dos elementos materiais analisados é possível inferir que a entrada no imóvel se mediante arrombamento, com a utilização de instrumento à guisa de percussão, combinado com força muscular" (fls. 138).

Portanto, deve ser afastada a qualificadora da escalada disposta na denúncia, permanecendo, intacta contudo a qualificadora do arrombamento.

Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é primário, consoante certidão juntada aos autos e não possui antecedentes criminais. (fls. 30). Assim sendo lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Assim sendo, a pena base deve ser mantida no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante prevista no art. 61, inc.II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, respeitadas posições em contrário, e em que pese as alegações da defesa, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando-se a 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito

Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos Autos nº 1509419-67.2020: "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

STF- "Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite

especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

Outrossim, não há atenuantes a se considerar. Com efeito, embora a Defesa tenha mencionado em seus memoriais que a réu teria confessado o delito, o réu não foi encontrado para ser intimado e ouvido em sede de instrução e ao ser ouvido em sede administrativa (fls. 05), se manteve em silêncio.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ao contrário do alegado pela Defesa comprovado está que o delito foi cometido durante o repouso noturno, tal fato foi mencionado pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida, nas quais afirmou que os fatos se deram na madrugada, fato este inclusive que consta do boletim de ocorrência de fls.08/11. Assim sendo, a presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155 §1º, do Código Penal, devendo assim a pena ser aumentada em 1/3, perfazendo o total de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Também é caso de se reconhecer a tentativa e considerando o iter criminis percorrido pelo acusado que foi abordado pela polícia, já tendo separado os objetos para serem levados, a pena deve ser diminuída pela metade, chegando-se a 1 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 07 dias-multa.

Considerando, no mais, que não há nos autos provas da condição econômica do acusado fixa-se a pena de multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto julgo parcialmente procedente a ação penal, para o fim de condenar o réu como incurso no art. 155, § 4º, inciso, I, combinado com art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, aplicando-se ao réu a pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa, fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas das condições financeiras do acusado, que foi inclusive defendido pela Defensoria Pública local.

Os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena, autorizam a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos, que ficam ora estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída, e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser destinada à entidade pública ou privada com destinação pessoal, que deverão ser determinadas no Juízo da Execução, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Em hipótese de revogação, o regime de cumprimento da pena por este delito será o aberto.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade e, ainda, a aplicação de regime aberto para o caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, poderá o réu recorrer em liberdade.
Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.
Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e comunique-se a vítima consoante disposição legal.
P.R.I.C.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA